

1502495-62.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Nobrega Feitosa

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... a terceiros, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como a causa de aumento, é medida de rigor, pelo que não cabe acolhimento a tese absolutória sustentada pela douta defesa.

Restou configurada, também, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da mesma Lei (tráfico no interior de estabelecimento prisional), sendo indiferente que a droga não tenha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n.º 01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502495-62.2020.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital n.º:

1502495-62.2020.8.26.0544 - Controle n.º 4141/2020

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290447/2020 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 14808670 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3854/20/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2290447 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA RODRIGUES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Nobrega Feitosa

Vistos.

GABRIELA RODRIGUES DA SILVA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso nas sanções cominadas no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 22 de novembro de 2020, por volta de 9h00min, nas dependências do CDP de Franco da Rocha, situado na Rua Marcos Góes, 01, Vila Benedito, nesta cidade e comarca, estaria trazendo consigo, para

supostos fins de entrega a terceiros, 01 (um) invólucro de cocaína, pesando, aproximadamente 47g (quarenta e sete gramas) de massa bruta e 28 (vinte e oito) pedaços de papel, pesando, aproximadamente, 16g (dezesesseis gramas), da substância conhecida como "K4"; substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos da denúncia de fls. 58/59.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifico a ausência de quaisquer nulidades, bem como não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo que passo à apreciação do mérito.

A materialidade delitiva se encontra consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 02/04, no auto de exibição e apreensão de fl. 05, no laudo de constatação provisória de entorpecente de fls. 17/21, no laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 86/88, bem como na prova oral coligida.

A acusada, em delegacia, à fl. 13, sobre os fatos apenas confessou que entrou com as drogas no presídio, ocultadas em suas partes íntimas e que prestaria mais informações somente em juízo.

Em juízo, a acusada disse que são verdadeiros os fatos. Disse que foi visitar o acusado dias antes e percebeu que ele estava bastante agitado, nervoso, e por ele ser dependente de droga, resolveu levar ao acusado a fim de vê-lo melhor. Disse que o acusado era usuário de cocaína e de "K4". A quantidade levada daria para fazer uso por uns quatro dias.

A agente de segurança penitenciária Sara Maira Bucher Neves, em delegacia, à fl. 08, disse que "(...) durante o procedimento de revista nos visitantes que adentravam ao setor de carceragem, ao submeter a senhora GABRIELA RODRIGUES DA SILVA, a qual visita o preso Murilo na qualidade de companheira, ao equipamento Scanner, foi notado na imagem que havia um volume estranho na altura da cintura. Imediatamente ao indagar a visitante a mesma confessou que trazia consigo uma quantidade de droga introduzida em sua vagina, e que pretendia levar para o interior da Unidade Prisional. Em seguida, a visitante acompanhou a depoente para uma sala reservada e espontaneamente retirou de seu órgão genital um invólucro que, após aberto, revelou conter substância esbranquiçada em pó análogo a cocaína e diversos papéis de tamanhos variados entre 20 e 4 cm semelhante a droga K-4. Diante do exposto, a visitante fora então conduzida a esta Delegacia de Polícia e apresentada a Autoridade Policial". No mesmo sentido foi o depoimento do agente de segurança penitenciário Paulo Henrique de Oliveira, ouvido em delegacia à fl. 10.

Em juízo, a agente penitenciária Sara disse que na data dos fatos prestava serviços na sala de revista, no equipamento de scanner; quando a ré passou pelo aparelho notou uma imagem estranha na altura da cintura. No mesmo momento, a ré afirmou que portava algo; solicitou que ela a acompanhasse e a própria ré retirou espontaneamente. A ré disse que não sabia o que era, mas que era para seu companheiro preso, Murilo

Por sua vez, o agente Paulo, em juízo, disse que em procedimento normal de revista pelo aparelho scanner, foi notado na imagem que havia algo diferente na altura da cintura da ré. Narrou que a funcionária Sara conversou com a acusada, a própria ré retirou o invólucro e entregou para eles. Disse que o invólucro tinha como destinatário o companheiro da acusada, mas ela negou saber do que se tratava no momento. O invólucro foi retirado de sua genitália.

Não há motivos para não se atribuir credibilidade aos depoimentos dos agentes públicos ouvidos nos autos, haja vista que são coerentes e harmônicos entre si, bem como porque não se demonstrou que elas poderiam ter qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa à acusada. Portanto, o simples fato de tais testemunhas serem agentes de segurança penitenciária não as torna desmerecedoras de confiança, de forma que caberia à ré a comprovação de razões ponderáveis para tanto.

Ademais, a jurisprudência tem admitido que, por se tratar de atos emanados de agentes da Administração Pública, os depoimentos prestados por agentes públicos, sejam policiais ou agentes de segurança penitenciária, possuem presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, afastável somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito:

“Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54).” (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime, grifei).

“Necessário ressaltar a importância das falas destes profissionais que, escolhidos pelo Estado para desempenhar nobre função, possuem fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque não restou provada qualquer intenção dos servidores em, de alguma forma, prejudicar o réu. Assim, não se pode desmerecer o depoimento de agentes policiais apenas por sua condição de agente da lei, consoante lição do mestre ARY BELFORT, que afirma: 'A tese da insuficiência testemunhal quando emane de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão.' (RJTJESP 136/477). Ao contrário: é testemunha que depõe compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções. Em sendo assim, tal depoimento reveste-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa inocente. Ademais, como afastaríamos tais palavras, se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as únicas testemunhas são os próprios policiais condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba sendo determinante para a condenação.” (Apelação nº 0006119-11.2012.8.26.0372 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Edison Brandão – julgado em 22 de abril de 2014 – votação unânime, grifei).

“Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções

não ficou sequer arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.” (Apelação nº 0000907-35.2012.8.26.0428 – 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Sérgio Coelho – julgado em 29 de maio de 2014 – votação unânime, grifei).

A quantidade de droga que foi apreendida, a saber, 01 (um) invólucro de cocaína, pesando, aproximadamente 47g (quarenta e sete gramas) de massa bruta e 28 (vinte e oito) pedaços de papel, pesando, aproximadamente, 16g (dezesesseis gramas), da substância conhecida como “K4”, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão (durante a revista para ingresso no interior de penitenciária), evidencia que, efetivamente, tal droga se destinava à entrega para consumo de terceiros dentro de estabelecimento prisional, pelo que ficou caracterizado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da mesma lei.

Sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, curial destacar que, o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de “ter em depósito”, “guardar”, “transportar” e “trazer consigo”, antes mesmo da atuação provocadora dos agentes públicos, o que afasta a tese de crime impossível.

Ademais, cumpre consignar que não se trata, no presente caso, de revista íntima vexatória. Este juízo entende que a prova decorrente da revista íntima é ilícita em casos de semelhante natureza. Ocorre que os fatos trazidos a estes autos não são semelhantes àqueles. Isto porque a própria acusada admitiu que, após passar pelo scanner corporal e assumir a posse das drogas, retirou o invólucro espontaneamente de sua vagina, em local apropriado. Indagada, relatou que não sofreu qualquer tipo de ameaça. O que muitas vezes ocorre em estabelecimentos prisionais desta comarca é a retirada dos entorpecentes da região genital feminina após procedimento de revista íntima, sem que seja dada a oportunidade para que a ré se apresente perante profissional adequado que lhe examine e, eventualmente, encontre as substâncias ilícitas. O presente caso é diametralmente oposto e o procedimento adotado pelas agentes de segurança encontra-se em total consonância com os princípios da razoabilidade e da dignidade humana. Ressalta-se, novamente, que a ré retirou a droga, presa a sua perna, espontaneamente, razão pela qual a prova originária do posterior procedimento não está eivada de qualquer ilicitude.

Por estarem comprovadas, portanto, autoria e materialidade delitivas, bem como o fato de que a substância entorpecente apreendida tinha destinação de entrega a terceiros, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como a causa de aumento, é medida de rigor, pelo que não cabe acolhimento a tese absolutória sustentada pela douta defesa.

Restou configurada, também, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da mesma Lei (tráfico no interior de estabelecimento prisional), sendo indiferente que a droga não tenha circulado pelo estabelecimento prisional, como estampado nos autos, tendo em vista que a lei não contém esta exigência, senão a de que a conduta seja praticada por alguém que esteja naquele local (posição do STJ), de maneira que não comporta acolhimento a tese absolutória sustentada pela defesa.

O acréscimo punitivo da agravante prevista no artigo 61, inciso I, alínea “j” do Código Penal, como requer o Ministério Público, no caso concreto, é injustificável, na medida em que não relacionado com o maior desvalor da conduta. Não há nos autos prova no sentido de que a ré tenha efetivamente se valido das fragilidades

ocasionadas pela pandemia para delinquir, sob pena de responsabilização objetiva. Portanto, inexistente qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública, despropositada sua aplicação.

Passo à aplicação da pena.

Atendendo às disposições constantes do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, bem como ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, verifico que a acusada, na data dos fatos, era primária e possuía bons antecedentes (fls. 74/75), não havendo informações nos autos acerca de sua personalidade ou de sua conduta social. Não se pode desprezar, entretanto, a natureza das drogas que foram apreendidas, circunstância esta que será analisada quando da terceira fase da dosimetria da pena, conforme alteração de entendimento deste juízo, no sentido de que a consideração da natureza da droga em duas fases da dosimetria caracterizar-se-ia bis in idem, pelo que fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase da aplicação da pena, ante o teor da Súmula 231 do STJ, apesar de sua confissão espontânea, a qual não pode ser considerada, tendo em vista o entendimento majoritário do STJ (Resp 1.117.073/PR e Resp 1.117.068), ressaltando o entendimento diverso deste juízo, porém acatando a decisão do E. Tribunal Superior, a fim de dar cumprimento à racionalidade das decisões do Poder Judiciário.

Na terceira fase, aumento a pena do crime de tráfico de drogas em 1/6, ante o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, levando-a ao patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ainda na terceira fase, verifico que a ré é primária, possuidora de bons antecedentes e que não há nos autos quaisquer indicativos de que ela se dedicaria a atividades delitivas ou integraria qualquer organização criminosa, pelo que é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, de 1/6 a 2/3. Registre-se que quando o legislador estipulou a aplicação do redutor “nos delitos definidos no caput e parágrafo 1º deste artigo”, não teve a intenção de afastá-lo das condutas previstas no artigo 40 da Lei de Drogas, conquanto apenas qualificam aquelas já arroladas no artigo 33, caput e parágrafo 1º, não criando novo tipo legal.

É fundamental, outrossim, observar que o legislador não estipulou os critérios para a diminuição exigida pelo dispositivo legal em tela, apenas mencionando que o Magistrado deve reduzir a pena de 1/6 a 2/3.

Ante a omissão legislativa, o julgador deve se pautar pelos elementos do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, de forma que a natureza, a quantidade, e a diversidade das substâncias entorpecentes devem ser levadas em consideração para se chegar ao quantum referente à diminuição da pena.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. (HC 229.694/MG, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz, DJ de 17 de dezembro de 2013).

No caso dos autos, a natureza das substâncias entorpecentes que foram apreendidas em poder da ré cria óbice a que seja aplicada a máxima diminuição de pena prevista

em lei, pelo que considero adequado fixar o quantum da redução em 1/3, tornando a pena definitiva em 03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA, por não haver outras circunstâncias a considerar.

O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º, e 3º, do Código Penal, bem como à observância do artigo 42 da Lei 11.343/06, haja vista que, em que pese a pena fixada não supere quatro anos, a natureza do entorpecente apreendido recomenda a fixação de regime mais gravoso. Também não é de fixar regime fechado no presente caso, tendo em vista que o regime fixado se mostra suficiente à reprovação do delito, sobretudo diante da primariedade da ré.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, isto é, um trigésimo do salário mínimo vigente no dia do fato, corrigido e executado em sede de execução, nos termos dos artigos 49, parágrafo 2º e 51, ambos do Código Penal, por não haver provas nos autos de que a ré possuía boa situação financeira.

Por ser a pena ora fixada não superior a quatro anos, bem como por estarem preenchidos os demais requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções, sendo uma delas a prestação de serviços à comunidade.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, para o fim de CONDENAR a acusada GABRIELA RODRIGUES DA SILVA, qualificada nos autos, à pena privativa de liberdade de 03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, no regime inicial SEMIABERTO, substituída por PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, E A SEGUNDA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS A SER FIXADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, bem como à pena de 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA, com a diária no mínimo legal, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, caput, §4º, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Poderá a ré apelar em liberdade, uma vez que respondeu solta ao presente feito, o que demonstra não ser necessária sua prisão cautelar.

Condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Providencie-se a incineração da substância entorpecente apreendida (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06).

P.I.C.

Franco da Rocha, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA